

TRIBUNAL PLENO - SESSÃO: 29/05/2024
EXAME PRÉVIO DE EDITAL
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-001)

Processo: TC 008472.989.24-3.

Representante: Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda.

Representada: Prefeitura Municipal de Ubarana.

Responsável pela Representada: Vanderlei Rodrigues da Cruz – Prefeito.

Assunto: Representação que visa ao exame prévio do edital da Chamada Pública nº 001/2024, processo administrativo nº 005/2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Ubarana, que tem por objeto o credenciamento de empresa especializada em administração, implementação, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos/magnéticos tipo cartão alimentação e refeição com chip de segurança e/ou com tecnologia de comunicação por aproximação (NFC, QRCODE ou similares), destinados aos beneficiários fixados pela Lei Municipal nº 769/2013 de 06 de março de 2013, para uso exclusivo em estabelecimentos credenciados, tais como atacados, hipermercados, supermercados, minimercados, empórios, mercearias e estabelecimentos congêneres, sem qualquer ônus, direto ou indireto para Administração Municipal e/ou para seus servidores.

Valor estimado: R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais).

Procurador de Contas: Celso Augusto Matuck Feres Junior.

Advogado cadastrados no e-tcesp: Rafael Prudente Carvalho Silva (OAB/SP 288.403); Wagner Cesar Galdioli Polizel (OAB/SP 184.881).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. CHAMADA PÚBLICA. CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS TIPO CARTÃO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS PARA O CREDENCIAMENTO. CORREÇÃO DETERMINADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA** em face do edital da Chamada Pública nº 001/2024, processo administrativo nº 005/2024, promovida pela **PREFEITURA**

MUNICIPAL DE UBARANA, que tem por objeto o credenciamento de empresa especializada em administração, implementação, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos/magnéticos tipo cartão alimentação e refeição com chip de segurança e/ou com tecnologia de comunicação por aproximação (NFC, QRCODE ou similares), destinados aos beneficiários fixados pela Lei Municipal nº 769/2013 de 06 de março de 2013, para uso exclusivo em estabelecimentos credenciados, tais como atacados, hipermercados, supermercados, minimercados, empórios, mercearias e estabelecimentos congêneres, sem qualquer ônus, direto ou indireto para Administração Municipal e/ou para seus servidores.

1.2. A Representante contesta as seguintes disposições do ato convocatório:

1.2.1. Critério de escolha da empresa contratada¹, que faz com que o credenciamento resulte na contratação de apenas uma empresa, que será a que conquistar maioria de votos dos servidores, em possível desvirtuamento do credenciamento;

Acrescenta que a referida regra vai acabar por extirpar do mercado as empresas que são ME/EPP e que possuem o direito de preferência na contratação, na forma do §2º do artigo 60 da Lei 14.133/2021 e articula que qualquer empresa habilitada poderá ser contratada, desde que seja escolhida por algum colaborador.

¹ 11.8 Será realizada uma votação majoritária para escolha dentre as empresas credenciadas que atenderam aos requisitos estabelecidos no edital.

(...)

13.3 Os servidores, realizarão a escolha, por maioria de votos, e poderão optar entre todas as empresas credenciadas qual a empresa que administrará o benefício.

13.4 Caso a empresa não atinja a maioria descrita no item anterior (empate), os colaboradores devem refazer a escolha entre as empresas que atingiram o mesmo número de votos.

1.2.2. Exigência de apresentação da rede de estabelecimentos credenciados no município de Ubarana e região na fase de habilitação², ainda que o edital preveja que a informação não será considerada como critério de habilitação ou eliminação dos proponentes ao credenciamento;

Anota que nenhum outro dispositivo dispõe sobre regras para a demonstração da rede credenciada e que, da forma como está, o edital faz com que a empresa que deseja concorrer ao objeto licitatório credencie estabelecimentos antes mesmo de ter sido convocada para a assinatura do contrato, o que impede a participação de diversas licitantes que ainda não atuam na região onde será prestado o serviço licitado.

Postula a fixação de prazo hábil de no mínimo 60 (sessenta) dias úteis para apresentação integral da rede de estabelecimentos credenciados, após a assinatura do contrato, e ou que haja um escalonamento, uma regra gradativa para que a empresa vencedora vá apresentando a relação de estabelecimentos exigidos.

1.2.3. Requisição de informação sobre o índice percentual cobrado pelos estabelecimentos comerciais, sobre as transações realizadas com o Cartão Alimentação³, dado que a Representante alega pertencer à relação entre particulares, e que não cabe à Administração interferir nestes acordos comerciais e sequer usar como critério de escolha para os beneficiários.

Ressalta que *“não é permitido ao órgão licitante intervir na negociação entre a Contratada e sua rede credenciada cobrando O ÍNDICE DO PERCENTUAL COBRADO PELOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, SOBRE AS TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O CARTÃO ALIMENTAÇÃO, tampouco na forma*

² 7.4 Apresentar a rede de estabelecimentos credenciados no município de Ubarana e região, sendo que esta informação não será considerada como critério de habilitação ou eliminação dos proponentes ao credenciamento.

³ 7.5 O Índice do Percentual cobrado pelos estabelecimentos comerciais, sobre as transações realizadas com o Cartão Alimentação, visando à transparência e conhecimento dos servidores que irão escolher.

de contratação dos estabelecimentos a serem credenciados, onde por meio deste, disponibilizam os recursos a serem adquiridos pelos servidores”.

1.3. Nestes termos, requereu fosse determinada a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. As regras de seleção do ato convocatório denotam um procedimento de credenciamento que resultará na seleção de apenas uma empresa, em possível desvirtuamento das finalidades do procedimento auxiliar disciplinado no artigo 79 da Lei 14.133/21, agravado pela requisição de rede credenciada e de divulgação de condições comerciais entre as operadoras e seus estabelecimentos credenciados, com possível interferência na escolha atribuída aos futuros beneficiários, levantaram indícios de possível contrariedade ao entendimento predominante na jurisprudência desta Corte sobre a matéria, razão pela qual a matéria foi submetida ao Tribunal Pleno na sessão de 20/03/2024, ocasião em que foi deferida a medida liminar de suspensão do certame e determinado o processamento da Representação como exame prévio de edital, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias à **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA** para a apresentação de suas alegações e justificativas às insurgências constantes da representação, juntamente com todos os demais elementos relativos ao procedimento licitatório.

1.5. Notificada, a Municipalidade apresentou justificativas e esclarecimentos por meio dos quais defende a conformidade do ato convocatório (evento 30).

1.6. A **Assessoria Técnico-Jurídica** (evento 38.1), **Chefia de ATJ** (evento 38.2) e **Ministério Público de Contas** (evento 43) concluíram no sentido da **procedência parcial** da Representação.

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SESSÃO: 29/05/2024
TC-008472.989.24-3

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA** em face do edital da Chamada Pública nº 001/2024, processo administrativo nº 005/2024, promovida pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA**, que tem por objeto o credenciamento de empresa especializada em administração, implementação, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos/magnéticos tipo cartão alimentação e refeição com chip de segurança e/ou com tecnologia de comunicação por aproximação (NFC, QRCODE ou similares), destinados aos beneficiários fixados pela Lei Municipal nº 769/2013 de 06 de março de 2013, para uso exclusivo em estabelecimentos credenciados, tais como atacados, hipermercados, supermercados, minimercados, empórios, mercearias e estabelecimentos congêneres, sem qualquer ônus, direto ou indireto para Administração Municipal e/ou para seus servidores.

2.2. Início pelo questionamento relacionado ao critério de escolha da empresa a ser contratada, que se mostra procedente, haja vista que a regra do edital⁴ contraria o disposto no inciso I do parágrafo único do artigo 79 da Lei 14.133/21, que determina que a “Administração deverá divulgar e manter à disposição do público, em sítio eletrônico oficial, edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados”.

De acordo com o observado no voto que concedeu a liminar de suspensão do certame, as regras de seleção do ato convocatório denotam um

⁴ Subitem 11.8 Será realizada uma votação majoritária para escolha dentre as empresas credenciadas que atenderam aos requisitos estabelecidos no edital.

procedimento de credenciamento que resultará na seleção de apenas uma empresa, desvirtuando as finalidades do procedimento disciplinado no artigo 79 da Lei 14.133/21.

Não é demais lembrar que o credenciamento é procedimento auxiliar das licitações e das contratações, caracterizando-se como processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados⁵.

Conforme destacado pela Assessoria Técnico-Jurídica em sua manifestação, “o sistema de credenciamento tem como uma de suas bases a contratação de todos os interessados que preencham as condições estabelecidas pela administração pública, sendo que por força do inciso I, parágrafo único do art. 79 da NLLC, o período do credenciamento deverá manter-se permanentemente aberto, apto a receber qualquer interessado que apresente a documentação, enquanto a Administração possuir interesse na contratação, sendo vedado, uma vez mais, a contratação de empresa única ou a recusa no credenciamento de novas empresas que atendam os critérios do edital no período da execução do objeto”.

Além disso, o fornecimento de vale alimentação e refeição, objeto que a Prefeitura de Ubarana pretende contratar, insere-se na hipótese prevista no artigo 79, II, da Lei 14.133/21⁶, onde é transferida ao usuário direto do serviço a escolha da empresa que prestará o serviço, conforme seus critérios subjetivos e pessoais e de acordo com suas necessidades individuais.

⁵ Art. 6º, XLIII, art. 78, I e 79, da Lei Federal nº 14.133/2021.

⁶ II - com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação.

Assim, a Administração deve retificar o edital, conformando-o ao que prescreve a Lei Federal nº 14.133/2021, com a exclusão do subitem 11.8⁷, possibilitando que todas as empresas que atendam aos requisitos do ato convocatório possam ser consideradas aptas para serem contratadas pela Administração, transferindo-se a escolha para o usuário do serviço, de acordo com suas necessidades individuais.

2.3. Também se mostra procedente a crítica relacionada à requisição de informação sobre o índice percentual cobrado pelos estabelecimentos comerciais sobre as transações realizadas com o cartão alimentação (subitem 7.5⁸ do edital), caracterizando-se em interferência nas relações comerciais entre as operadoras e os estabelecimentos credenciados.

Assim, também neste aspecto, o ato convocatório demanda retificação, devendo ser excluído o subitem 7.5 do instrumento convocatório.

2.4. Em relação à exigência de apresentação da rede de estabelecimentos credenciados no município de Ubarana e região na fase de habilitação, a procedência é parcial.

Conforme destacado na instrução, embora seja cabível a exigência de rede credenciada, faltou clareza quanto ao subitem 7.4⁹ do edital e subitens 13.1.12¹⁰ e 13.1.13¹¹ do Termo de Referência (Anexo II), no que diz respeito aos “estabelecimentos credenciados no município de Ubarana e

⁷ 11.8 Será realizada uma votação majoritária para escolha dentre as empresas credenciadas que atenderam aos requisitos estabelecidos no edital.

⁸ 7.5 O Índice do Percentual cobrado pelos estabelecimentos comerciais, sobre as transações realizadas com o Cartão Alimentação, visando à transparência e conhecimento dos servidores que irão escolher.

⁹ 7.4 Apresentar a rede de estabelecimentos credenciados no município de Ubarana e região, sendo que esta informação não será considerada como critério de habilitação ou eliminação dos proponentes ao credenciamento.

¹⁰ 13.1.12. A empresa deverá manter credenciado no mínimo 05 (cinco) estabelecimentos, dentro do município de Ubarana.

Será Permitido o credenciamento de outros tipos de estabelecimentos, tais como minimercados, mercearias, empórios, quitandas, açougues, padarias, entre outros.

¹¹ 13.1.13. O Cartão Alimentação deverá ter estabelecimentos credenciados por todo estado de São Paulo.

Região”, número mínimo de 05 (cinco) estabelecimentos e obrigatoriedade de estabelecimentos credenciados por todo estado de São Paulo.

Há constatação da Chefia da Assessoria Técnica de que o instrumento convocatório não define a abrangência do termo “região”, impossibilitando saber quais os pressupostos necessários ao cumprimento do item 7.4.

Também se mostra desarrazoada a exigência de estabelecimentos credenciados por todo estado de São Paulo.

Assim, a Administração deve promover a revisão e retificação dos itens criticados (subitem 7.4 do edital e subitens 13.1.12 e 13.1.13 do Termo de Referência - Anexo II).

2.5. Por outro lado, aliado aos fundamentos consignados na instrução do autos, considero as demais insurgências, consistentes na ausência de direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte e fixação de prazo hábil de no mínimo 60 (sessenta) dias úteis para apresentação integral da rede de estabelecimentos credenciados, improcedentes.

2.6. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da Representação e determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA** que, em eventual relançamento do certame, altere o edital de modo a: **1)** excluir o subitem 11.8, conformando o edital às regras previstas na Lei Federal nº 14.133/2021; **2)** excluir o subitem 7.5; **3)** promover a revisão e retificação do subitem 7.4 do edital e dos subitens 13.1.12 e 13.1.13 do Termo de Referência (Anexo II).

Proponho, ainda, **recomendação** para que a Administração revise e retifique, em sua totalidade, o edital e seus anexos, com exclusão de

regras em descompasso com os preceitos que regem o credenciamento, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, para oferecimento das propostas.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Dimas Ramalho
Conselheiro